

1501604-68.2020.8.26.0535
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Glaucio Roberto Brittes de Araujo
Comarca: Guarulhos
Foro: Foro de Guarulhos
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/08/2022
... 02/08/2021; Data de Registro: 02/08/2021)

"Tráfico de Drogas e Associação para o tráfico - Recurso defensivo buscado a absolvição - Acolhimento parcial - Tráfico de drogas bem demonstrado - Testemunhos policiais seguros e coerentes - Expressiva quantidade de droga a indicar a finalidade mercantil - Condenação mantida - Inexistência de provas concretas a indicar o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guarulhos
Foro de Guarulhos
4ª Vara Criminal
Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501604-68.2020.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501604-68.2020.8.26.0535
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2188652/2020 - DISE-DEL.SEC.GUARULHOS, 12780326 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 106/20/222 - DISE-DEL.SEC.GUARULHOS, 2188652 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MATHEUS FELIPE ZIZUATO RODRIGUES
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Glaucio Roberto Brittes de Araujo

VISTOS.

MATHEUS FELIPE ZIZUATO RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 29 do Código Penal, art. 35 da Lei nº 11.343/06, art. 129, caput, c.c. §12, do CP e art. 329, caput, do CP, na forma do art. 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia no dia 03 de agosto de 2020, por volta das 13h30, na Estrada das Lavras, 3158, nesta cidade e comarca, o agente supramencionado, previamente conluiado com o adolescente Carlos Eduardo Aparecido da Silva Souza, com unidade de designios e identidade de propósitos, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 04 porções de cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 2,79g, e 05 porções de cocaína, acondicionadas em tubos plásticos (tipo eppendorfs) pesando aproximadamente 3,02g, e 12 frascos de lança-perfumes, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação de fls. 17/21 e laudos de exame químico-toxicológico a fls. 60/62 e 79/81).

Consta, também, que, nas mesmas condições de tempo e local, o agente supramencionado se opôs à execução de ato legal, mediante violência contra funcionário competente para executá-lo.

Consta, ademais, que, nas mesmas condições de tempo e local, o agente supramencionado ofendeu a integridade corporal de Fabricio Souza Leão, policial civil, provocando-lhe lesões corporais descritas no laudo de exame corporal de fls. 65/66 (natureza leve).

Consta, por fim, que, nas mesmas condições de local acima mencionadas, em período anterior não precisado, o agente supramencionado se associou com o adolescente Carlos Eduardo Aparecido da Silva Souza, para o fim de praticar, na cidade de Suzano, o comércio ilícito de drogas, crime esse previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi oferecida. O réu foi notificado e apresentou resposta à acusação. A denúncia foi recebida e, não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns à acusação e defesa, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, em debates, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria, postulou fixação da pena base acima do mínimo legal, ante a quantidade e natureza das drogas, regime fechado, sem substituição por restritiva de direitos.

A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP e, subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal, atenuante da menoridade relativa, aplicação do redutor do privilégio, regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas, resistência e lesão corporal ficaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação

provisória, pelo laudo do exame químico-toxicológico definitivo e pela prova oral a seguir examinada. A esqualidez do complexo probatório da associação, contudo, não autoriza condenação.

A quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento das drogas, a quantia em dinheiro apreendida R\$99,00 (fls. 14) e as circunstâncias da posse evidenciam que o entorpecente seria fornecido a terceiros. A conduta corresponde, perfeitamente, ao tipo penal do art. 33, da Lei 11.343/06. A autoria é igualmente indubitosa, considerando todo o conjunto probatório.

O réu negou vagamente a prática delitiva, alegando que tinha ido ao local comprar drogas e chegou junto com o suposto policial. Aduziu que tem conseguido ficar sem consumir entorpecente e negou que tivesse reagido à prisão. Alegou que “escorregaram”, quando foram prendê-lo. Admitiu que não conhecia os policiais, deixando de indicar justificativa para ter sido preso ilegalmente em coautoria pelo tráfico e não declinou os motivos para a descrição tão minuciosa dos seus atos ilícitos. Declarou ser primário e morar com a avó, tendo um endereço certo. A versão vaga, isolada e inverossímil acabou refutada pelas provas colhidas, enquanto a imputação encontrou sólido respaldo probatório. Vejamos.

O policial Fabrício afirmou que avistaram, em campana no condomínio, o movimento do tráfico e se aproximou, então, dos rapazes, apresentando-se como usuário. O acusado o atendeu e solicitou que levantasse a camisa. Como a arma estava nas suas costas e aquele não a notou, autorizou que o menor o servisse com as drogas. Nesse momento, deu voz de prisão e o maior atracou-se consigo, iniciando uma luta corporal. Destacou que um terceiro indivíduo fugiu e que o adolescente foi detido com os entorpecentes.

O policial Ricardo confirmou que o seu parceiro se passou por usuário, com a arma nas costas, motivo pelo qual o réu, depois de determinar que levantasse a camisa e sem notar o objeto, autorizou Fabrício a pegar a droga com o menor. Nesse momento, em razão do flagrante iminente, o réu se atracou com o seu parceiro, enquanto o terceiro e o menor fugiam. Como este último veio na sua direção, conseguiu detê-lo. Encontrou porções de drogas variadas em seu poder e recolheram ainda outras porções no chão, onde estavam os três indivíduos, não sabendo se estavam com o acusado ou se caíram durante a fuga do menor.

Como se percebe, os fatos narrados na exordial acusatória restaram comprovados, com exceção dos elementos típicos da associação para o tráfico, mormente estabilidade. Assim, o crime de tráfico de entorpecentes realizado naquela ocasião, a resistência e a lesão corporal no policial restaram devidamente demonstradas. Na data aludida, o acusado e o adolescente deliberaram por realizar a narcotraficância, em ponto de venda de drogas. Contudo, no momento em que a dupla realizava vendas, foi surpreendida por policiais, que observaram a dinâmica da coautoria, especialmente uma pessoa não identificada se aproximar deles, ser atendida pelo réu, entregar dinheiro, receber a droga retirada de uma sacola, e se evadir. Tão logo um dos policiais se aproximou, passando-se por usuário, o acusado o recebeu para triagem e, ante a resposta de que desejava drogas, ordenou que levantasse a camiseta, certamente para confirmar que não era policial e autorizar seu contato com o adolescente, o qual portava as porções prontas para distribuição. Ato contínuo, o policial se identificou e o acusado reagiu, visando se opor à atuação legítima daquele. Investiu na sua direção, dando início a embate corporal, até que foi contido, mas deixando lesões na vítima. O adolescente e outro indivíduo não identificado que lá estava fugiram em direções opostas, tendo o primeiro, contudo, sido detido pelo parceiro de polícia. Feita a abordagem, em poder do adolescente foi encontrada a quantia em dinheiro de R\$ 99,00, produto do tráfico, e as drogas supramencionadas (04 porções de maconha, 05 de cocaína, e 12 frascos de lança-perfumes). Em razão das agressões, o policial Fabrício sofreu lesões corporais de natureza leve descritas no laudo (fls. 65/66- escoriações em antebraço esquerdo,

posterior de punho direito e lombar direito), sobrevivendo representação (fls. 78).

No caso em apreço, os testemunhos atestaram, em uníssono, com detalhes, coerência e firmeza, tal dinâmica do flagrante, a posse das drogas pelo réu em situação de comércio e sua reação sintomática, denotando plena adesão ao tráfico, enquanto a defesa não soube relatar sucessão de fatos diversa e convincente, bem como não cogitou de motivo para ser incriminado falsamente.

Não é crível, outrossim, que aquela quantidade de maconha, lança e cocaína se destinaria apenas ao uso pessoal, sobretudo em local público. Ademais, estava sendo visivelmente comercializada e chegou a ser oferecida ao policial, quando se acreditava ser usuário. A alegação vaga, isolada e ulterior de que o réu estava comprando, portanto, foi rebatida pelos testemunhos confiáveis, pelas evidências do dolo e da coautoria desse crime.

Além disso, não há razão concreta para desprezar as declarações de testemunhas sob compromisso formal, inclusive sobre o liame subjetivo com as drogas e sua função nas vendas, sobretudo quando são servidores imbuídos da defesa do interesse público e desconhecidos do réu. Saliente-se que merecem crédito e são dotados de valor probatório determinante, em delitos de tal jaez. Nesse sentido, há farta jurisprudência:

“O valor de depoimento testemunhal de policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC nº 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.1996).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POR POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. (...) 2. Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida - 24 (vinte e quatro) invólucros com crack - revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 3. Tem-se por adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena corporal de 5 (cinco) anos aplicada ao paciente pelo tráfico de drogas, dado o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal em conta do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas, não se olvidando a quantidade de entorpecente que trazia consigo. 4. Ordem denegada.” (STJ, HC nº 223086 / SP; 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.11.2013).

Não obstante os argumentos da Defesa, as provas da dinâmica dos fatos exposta na exordial são fartas, ao passo que a versão do interrogatório judicial não se mostrou dotada de sentido lógico e respaldo indiciário mínimo. Não é crível que os policiais incriminariam o usuário também, quando bastaria a apreensão do adolescente. Mais absurda ainda a ideia de que o réu ficaria no local por significativo lapso temporal, atenderia outra pessoa e a testemunha, se seu objetivo era apenas o de adquirir rapidamente alguma quantidade de droga. Assim, irrelevante se as porções estavam fisicamente em poder do menor, na medida em que o vínculo subjetivo com o material e a distribuição se estabeleceu em relação aos dois. Seus atos, inegavelmente de possuir e distribuir, sobretudo estando presente na cena da execução, representam efetivamente o domínio sobre o fato típico e não

simples participação, mormente de menor importância.

Nesse sentido, os relatos dos policiais, coerentes nas duas fases processuais, minuciosos, harmônicos, seguros e condizentes com os elementos sensíveis da infração, merecem prestígio, inclusive sobre a conduta típica do acusado, como autor e não mero partícipe. Não havia motivos, a propósito, para incriminar falsamente um desconhecido usuário, sem vantagem pessoal e sob risco de responsabilização funcional e criminal. Muito menos prestaríamos falsos testemunhos, em juízo, inexplicavelmente, para prejudicarmos um inocente. Também não sugerimos indícios de que a droga pertencesse a outrem, de mácula ou de equívoco no flagrante.

E o decreto condenatório não se baseia tão somente na palavra de policial ou nos dados do inquérito. No caso concreto, todos os elementos probatórios harmonizam-se, inclusive aqueles obtidos na fase judicial sobre a dinâmica da obtenção dos elementos sensíveis da infração, sendo certo que o magistrado pode utilizar todos na formação de seu convencimento. Ainda que assim não fosse, não há óbice à valoração, embora relativa, dos elementos colhidos na fase de investigação para fundamentar eventual decreto condenatório, porquanto a vedação legal é no sentido da impossibilidade de condenação lastreada exclusivamente em tais provas, nos exatos termos do art. 155 do CPP. Neste sentido, é a jurisprudência:

“(...) Mostra-se válida a condenação imposta com auxílio de dados obtidos na fase inquisitorial se tais estão em consonância com o apurado em juízo. O desprezo ao que se produziu na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em nosso ordenamento. Portanto, ainda que tenha a princípio menor valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode tal ser afastado de pronto. No caso dos autos a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, confirma e corrobora a prova produzida tão somente no inquérito policial. Assim a prova deve ser vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida, mas o valor probante, estando garantido os direitos constitucionais do réu, conforme acima exposto”. (TJ/SP, Apelação nº 0039765-66.2010.8.26.0506, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 28/04/2016).

No mais, em delitos de tal natureza, as evidências são determinantes para elucidação do vínculo subjetivo entre o agente e as drogas e de sua destinação, sendo inviável prova concreta e cabal do seu pensamento. De outro lado, não se alegou pronta e espontaneamente e não ficou evidenciado que toda aquela droga apreendida seria consumida.

De qualquer sorte, a quantidade, a variedade e forma de acondicionamento da droga, a quantia em dinheiro e as circunstâncias da ação revelaram sobrejamente a destinação a terceiros. Incabível, pois, eventual tese de insuficiência de provas ou desclassificação para art. 28, da lei.

O acusado é imputável e praticou os atos típicos descritos na norma penal. Justificativas relativas à situação econômica, ainda que, em tese, tivessem contribuído para a traficância, não são dirimentes da ilicitude ou da culpabilidade. Não justificam a despicienda ofensa ao bem jurídico.

Ficou comprovada, ainda, a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI ambos da Lei n. 11.343/06, porque inegável o envolvimento do menor, que estava com o réu na mercancia. Esse tinha o conhecimento de sua idade evidente. Jamais o negou, além de cognoscível sua condição de vulnerabilidade. Ressalte-se que a lei contenta-se com a circunstância objetiva, prejudicial ao desenvolvimento do menor, e prescinde da corrupção exercida pelo acusado, que configura outro crime. Basta que este aceite a realização do crime nessas condições, contribuindo para as

consequências perniciosas sobre o adolescente. Nenhuma prova de que não sabia da sua menoridade (o que jamais alegou), visível e cognoscível, aliás, a qualquer um, foi produzida. Ademais, despicienda a ascendência sobre ele, embora revelada pelas circunstâncias do flagrante.

Finalmente, nenhum álibi restou comprovado de maneira inequívoca e nenhuma excludente ficou configurada. Não pairam dúvidas sobre o liame subjetivo entre o réu e as drogas encontradas e sobre a finalidade de fornecimento a outrem, na companhia do adolescente.

Do mesmo modo, restou comprovado que o acusado se opôs à execução de ato legal, mediante violência contra funcionário público estadual, competente para executá-lo. Reitere-se que, de acordo com os depoimentos das testemunhas, não se limitou a fugir, descabendo qualquer tese de autodefesa, embora improcedente. Na verdade, o acusado ainda resistiu à execução da referida ordem legal, ante a situação de indiscutível flagrante. Não se tratou de mera desobediência, como desdobramento da autuação, mas de movimento corporal contra o policial, propiciando contato físico e visando obstar a prisão. Assim, as evidências da investida e do dolo de resistir à abordagem permitem o acolhimento deste pedido condenatório também. Rejeita-se, então, ilação sobre atipicidade por falta de dolo ou sobre contato casual e accidental. A prova oral revela a sequência de atos de afronta à ação do policial, não sendo possível afastar a culpabilidade e, por conseguinte, a responsabilidade do réu.

Melhor sorte não assiste ao réu no tocante à imputação do crime de lesão corporal. O acusado, ao ser abordado, ofendeu a integridade física de Fabricio Souza Leão, conforme constatação dos vestígios e descrição pelos depoentes do liame com sua iniciativa agressiva e unilateral. Com efeito, o policial civil, ao entregar o dinheiro e ser servido, identificou-se, mas o acusado, visando se opor à prisão, contra ele investiu, dando início a embate corporal e provocando-lhe lesões corporais descritas no laudo de exame corporal de fls. 65/66 (natureza leve). Somente foi contido, em seguida, com apoio do outro policial. Enfim, o conjunto probatório, mormente os testemunhos que revelam a procedência da narrativa da exordial, é suficiente para a condenação, enquanto nenhuma infração prévia dos servidores ficou cabalmente demonstrada cabalmente. Não se fez prova cabal de álibi ou de outra dinâmica dos fatos.

No que concerne à associação para o tráfico, todavia, o artigo 35 da Lei n. 11.343/06, não se contenta com o concurso eventual, mas pressupõe a estabilidade do vínculo associativo. Neste ponto, as provas não são suficientes. Não foram encetadas diligências prévias para confirmação de outras reuniões, manipulações e transações realizadas em conjunto pelos réus ou para elucidação de eventual divisão de tarefas, por período significativo. Não foram registradas denúncias específicas nesse sentido. Não se obteve resultado de interceptações telefônicas ou documentação apta a reforçar os indícios de que a empreitada conjunta era realizada há algum tempo. Não foram ouvidas testemunhas que tivessem conhecimento direto de sucessivos encontros ou entregas de droga. Não houve confissão ou delação. E o trabalho de inteligência da polícia não chegou a revelar a estabilidade da ação dos agentes.

Vale dizer, não existe prova inequívoca de que os réus se dedicavam ao tráfico, em conjunto, dividindo tarefas, mediante estrutura profissional, há muito tempo ou de que participavam de algum tipo de organização duradoura. Não há registros de outras transações que fossem suficientes para tal conclusão. Neste ponto, não é possível refutar completamente a hipótese de primeiro contato ou reunião para realizarem vendas. Em suma, temerária a condenação dos agentes pela prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06. A falta da comprovação da estabilidade prévia do grupo não pode ser suprida por conjecturas, como quantidade de substância e comentários informais de terceiros. Sobre a temática ora analisada:

"CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06) – APELOS DEFENSIVOS BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS. TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E CONDIÇÕES DO FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE NARRAÇÃO PORMENORIZADA NA DENÚNCIA, NÃO BASTANDO A SIMPLES MENÇÃO DE ESTAREM OS ACUSADOS ASSOCIADOS – PROVAS INSUFICIENTES EM RELAÇÃO A CRIME TAL, ADEMAIS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE QUE ELES ESTAVAM ASSOCIADOS ENTRE SI OU COM TERCEIROS PARA O NARCOTRÁFICO – NÃO DEMOSTRADO O VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE ELES, BEM COMO AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DIVISÃO DE TAREFAS – MERA COAUTORIA QUE NÃO CONFUNDE COM ASSOCIAÇÃO – PRECEDENTE – ABSOLVIÇÃO QUE ORA SE DECRETA. PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS – CRITERIOSAMENTE FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – PENAS NO MÍNIMO PARA A ACUSADA E MAJORADA PARA O OUTRO, DADOS OS MAUS ANTECEDENTES – REINCIDÊNCIA DO ÚLTIMO TAMBÉM BEM CONFIGURADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE "BIS IN IDEM", PORQUE FULCRADA EM CONDENAÇÃO DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PARA AMBOS OS ACUSADOS, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – REGIME FECHADO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSI" DESCABIDOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS". (TJSP; Apelação Criminal 1500516-96.2018.8.26.0621; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guaratinguetá - 1ª Vara; Data do Julgamento: 02/08/2021; Data de Registro: 02/08/2021)

"Tráfico de Drogas e Associação para o tráfico – Recurso defensivo buscado a absolvição – Acolhimento parcial – Tráfico de drogas bem demonstrado – Testemunhos policiais seguros e coerentes – Expressiva quantidade de droga a indicar a finalidade mercantil – Condenação mantida – Inexistência de provas concretas a indicar o vínculo associativo entre o réu e o menor – Possibilidade de mera comparsaria – Absolvição de rigor – Reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da lei de drogas capitulada na denúncia – Pena acrescida diante da quantidade de droga – Possibilidade – Réu primário e sem antecedentes – Privilégio possível – Irrelevância, para sua aplicação, do envolvimento de menor – Regime semiaberto suficiente diante da pena aplicada – Recurso defensivo parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 1501128-97.2019.8.26.0621; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piquete - Vara Única; Data do Julgamento: 29/07/2021; Data de Registro: 29/07/2021)

Portanto, comprovada a materialidade delitiva e evidenciada a autoria, ante o complexo probatório robusto e coerente produzido nos autos, impende apreciar a dosimetria da pena, fixando-a no patamar suficiente e necessário à reprovação do delito.

Bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, consistente em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa (tráfico), 2 meses de detenção (resistência) e 3 meses de detenção (lesão corporal), considerando a primariedade do acusado (fls. 34/35). A quantidade não extrapola o natural na caracterização do tráfico em situações de tal jaez, já é considerada na configuração da destinação a terceiros e no emprego de redução menor na terceira fase, não sendo usada aqui para majoração, sob pena de bis in idem.

Na segunda fase, resta prejudicada a atenuante da menoridade relativa, haja vista a impossibilidade de redução da pena aquém no mínimo legal, nesta fase.

Na terceira etapa, incide a causa de aumento (envolvimento de um menor), justificando-se majoração apenas de 1/6 (um menor), que resulta pena de 5 anos e 10

meses de reclusão, além de 583 dias-multa. Por ser a vítima integrante da força de segurança pública, conforme o §12º do artigo 129, a pena da lesão é aumentada de 1/3, resultando em 4 meses de detenção. A resistência poderia ter sido cometida contra servidor de categoria diversa, não se vislumbrando bis in idem no tratamento diferenciado das vítimas mais expostas às infrações dessa espécie.

Tendo em vista a primariedade do réu e a ausência de prova de envolvimento em organização ou dedicação à atividade criminosa, adota-se a causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 em 1/2, totalizando 2 anos e 11 meses de reclusão, além de 291 dias-multa. Com efeito, não há prova suficiente de dedicação ao tráfico. Não foram encetadas diligências exitosas sobre o vínculo permanente do réu com a criminalidade. Sob o crivo do contraditório, não se demonstrou, de maneira inequívoca, a dedicação atual à atividade criminosa, mormente tráfico, que o distinguísse do traficante iniciante ou “de primeira viagem”.

À míngua de critérios seguros e explicitamente estabelecidos para a aplicação do art. 33, par. 4, da Lei 11343/06, o art. 42 do referido diploma legal deve orientar o patamar daquela redução. Restringir este preceito à fase do art. 59, do Código Penal, a par de despiciendo, criaria distinção injustificada em relação a outros delitos, na primeira etapa de dosimetria da pena, e não permitiria solução eficaz para a controvérsia acerca dos critérios de redução da terceira fase.

Por conseguinte, no caso em apreço, ante a quantidade e a natureza de parte da droga, não se exige a redução máxima, estando preservado o prudente arbítrio do julgador. A propósito, a lei estabelece somente que as penas “poderão” ser reduzidas. Além disso, entende-se que por se tratar de causa de redução como simples benefício – que já pode ir além do mínimo legal – e não de dosimetria da primeira fase, não se adota a pena menor em perspectiva (diminuição máxima) como regra. Muito pelo contrário, a legislação recente destinou-se ao agravamento da coibição, da repressão e da resposta penal para o tráfico de entorpecentes, sendo ilógica e dissociada do princípio da razoabilidade a exigência peremptória da diminuição máxima da pena, que a levaria a um patamar muito inferior ao da lei antiga.

Segundo exegese sistemática e teleológica das normas sobre a matéria, o percentual de diminuição deve ser escolhido de acordo com o caso concreto e a especificidade do potencial lesivo da conduta, como possível número de usuários em perspectiva. Ausente prova de efetivo comando e gerência na região, por outro lado, descabida a redução mínima da sanção.

As penas de detenção devem ser somadas, pois as condutas lesaram bens jurídicos diversos e os delitos são diferentes, tendo sido praticados em condições próprias e com desígnios autônomos. Não se cogita, então, de absorção ou de concurso formal, até porque expressamente a resistência é punida, sem prejuízo da lesão corporal, se ocorrer, como no caso concreto, totalizando, a pena, 6 meses detenção, em regime aberto.

No mesmo sentido, impõe-se o reconhecimento do concurso material desses crimes com o de tráfico. Neste ponto, ante a pena definitiva de 2 anos e 11 meses de reclusão, cabe o regime inicial aberto para o cumprimento, tendo em vista ainda o “privilegio”, a natureza do crime (sem violência ou ameaça que poderia exigir o fechado) e as circunstâncias favoráveis do artigo 59, do CP. Por se tratar de tráfico de drogas privilegiado, cumpre observar decisões recentes dos Tribunais Superiores no sentido de que o referido crime não é hediondo e enseja regime compatível com a quantidade da pena, sem prejuízo da possibilidade de outro mais gravoso (aqui aberto) em razão de fatores específicos, ausentes no caso concreto. Sobre a temática, confira-se:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO.

ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTÁRIOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE". (STJ, HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1) - Decisão Monocrática- Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

Ademais, tal conclusão também decorre da Lei de Execuções Penais, com as alterações trazidas pelo pacote anticrime (Lei n.º 13.964/2019), mais precisamente da redação art. 112, § 5º da LEP: "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006."

No mesmo sentido, por causa da quantidade da pena e da primariedade, as penas de detenção serão cumpridas no aberto, após o cumprimento das de reclusão.

Por fim, preenchidos, por conseguinte, os requisitos do art. 44 do CP, à luz da pena total aplicada (3 anos e 5 meses de restrição de liberdade) e da primariedade, sendo ainda socialmente recomendável, concede-se a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena total a uma entidade com função social, e prestação pecuniária de um salário-mínimo especificadas oportunamente pelo juízo da execução.

Ante todo o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do Órgão Ministerial para CONDENAR o réu MATHEUS FELIPE ZIZUATO RODRIGUES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inc. VI, c.c. §4º, da Lei nº 11.343/06, artigo 129, caput, c.c. §12, do CP e artigo 329, caput, do CP, na forma do art. 69 do Código Penal, na pena privativa de liberdade de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e 6 meses de detenção, em regime aberto, substituídas por prestação gratuita de serviços à comunidade pelo prazo total de restrição de liberdade e prestação pecuniária de um salário-mínimo a entidade com função social, em condições especificadas na execução, além de 291 dias-multa pelo valor unitário mínimo, e para ABSOLVÊ-LO da imputação do artigo 35 da Lei 11343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O réu poderá apelar em liberdade, pois concedida a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura Clausulado, em favor do acusado. Transitada esta em julgado, far-se-á a necessária comunicação ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Declaro o perdimento do dinheiro em favor da União, ante as evidências do liame com o tráfico, e determino a incineração da droga apreendida.

Custas e despesas processuais pelo sentenciado, observada a gratuidade. P.I.C.

Guarulhos, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA